

1516612-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... no presente feito.

Cito:

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório." (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

"PROVA - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516612-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516612-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199390/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 26301166 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2199390 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Ferreira Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

JONAS FERREIRA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, porque no dia em 22 de julho de 2022, por volta de 22h30min, na Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Melo, altura do nº 1000, Vila Prudente, nesta Capital, agindo em unidade de desígnios e concurso de agentes, com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercidas com simulacro de arma de fogo e emprego de arma de fogo, subtraiu, para eles, um aparelho de telefone celular, da marca Motorola G9, de propriedade da vítima Marcio Perez Bonfati.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o ofendido Marcio conduzia seu veículo Hyundai Creta, com sua esposa e filha, na Avenida Anhaia Mello, sentido Centro, momento em que parou o carro no farol e foi abordado pelo denunciado e seu comparsa, um de cada lado, com emprego de arma de fogo e um simulacro. Assim, mediante grave ameaça, um dos roubadores colocou a arma pela janela do motorista e a apontou para a cabeça da vítima, enquanto o outro bateu a arma na janela do passageiro, onde estava a esposa da vítima, tentando abrir a porta do carro.

Amedrontado, Marcio entregou seu aparelho de telefone celular aos roubadores. Os assaltantes, então, dirigiram-se ao veículo Fiat Palio, que estava parado atrás do Hyundai Creta. No entanto, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo policial militar Cristiano Junior Rubio de Melo, que era o condutor, e que, após ter visto o roubo sofrido por Marcio, ao perceber os criminosos partirem na direção de seu veículo, agiu em legítima defesa e atirou.

O denunciado e seu comparsa conseguiram se evadir, embora JONAS tenha sido baleado pelo policial e buscado socorro ao Pronto Socorro do Ipiranga.

Na ocasião, JONAS foi reconhecido por Cristiano e pelo ofendido Marcio como um dos autores do roubo.

Em poder do acusado, foi localizado o aparelho de telefone celular subtraído de Marcio (fls.20/21). Também foi apreendido, no local dos fatos, o simulacro de arma de fogo utilizado para a prática do crime (fls.17/18).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 35/39).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2022 (fls. 88/90).

O réu foi citado, apresentou resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após interrogado o acusado (mídias digitais).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, postulou a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto. Subsidiariamente, requereu o afastamento da arma de fogo, pena no mínimo legal, compensação da confissão com a reincidência, aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 17/18 e de entrega de fls. 20/21, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/08, pelo laudo pericial de fls. 152/155 (simulacro de arma) e pela prova oral coligida nos autos.

Assim, o acusado foi preso em poder do bem subtraído. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório.” (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade.” (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

A autoria do delito pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

Em seu interrogatório judicial, o réu CONFESSOU a prática do delito. Estava com outra pessoa, abordou o motorista, estava com um simulacro. Não viu se o parceiro abordou o outro lado do carro. a vítima deu o celular, quando virou as costas para ir embora, um segurança desceu e atirou contra ele, foi atingido oito vezes.

Conseguiu sair correndo, pediu ajuda na rua, e lhe socorreram para o hospital do Ipiranga. Ficou cinco dias internado, passou por cirurgia, foi preso no hospital.

Foi processado por roubo duas vezes, estava há cinco meses na rua.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Marcio RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito. Estava parado no semáforo em seu veículo, estava com o vidro aberto cerca de três dedos, apareceu uma pessoa enfiando o revólver dentro de seu carro, em sua cabeça, outro roubo estava tentando abrir a porta de sua esposa e ele pegou o celular e saiu, um policial que estava atrás e atirou, reagindo. O outro que batia no carro do lado de sua esposa também estava armado. Sua esposa entregou o celular para o que estava do seu lado. O réu foi alvejado e foi para o hospital. Recuperou o celular e pode dizer que a pessoa que foi alvejada e presa é o que lhe roubou.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque não há nada nos autos capaz de infirmar suas alegações.

A testemunha Cristiano Augusto Codonho Ferreira disse que viu o que acontecia no primeiro disparo. Estava atrás do Palio, que estava atrás do Creta da vítima. Trocava a música e levantou a cabeça e viu uma pessoa à paisana efetuando diversos disparos. Ele atirou contra o indivíduo de moletom branco, que conseguiu fugir. Eram dois os roubadores. Esse de moletom branco não foi identificado. Depois ele fez disparos contra o acusado, acertou alguns, e ele se jogou no meio-fio. Ele tinha um revólver também, o acusado, o policial chutou a arma dele e recolheu. Mesmo machucado o acusado fugiu. A pessoa foi detida no hospital.

Já o policial militar Diego Freitas Da Silva, reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando souberam do roubo e da reação do policial Cristiano, chegaram no apoio.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência

pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

E a jurisprudência:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada” (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

“O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade” (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

De rigor o reconhecimento das majorantes do emprego da arma e do concurso de agentes, vez que a vítima afirmou ter sido roubada por dois agentes, ambos armados. Ademais, consoante já decidiram o C. STJ e o E. TJSP, não é necessário para o reconhecimento da causa de aumento de pena do roubo consistente no uso de arma de fogo a apreensão ou perícia dela:

“PROCESSO PENAL (...) Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos das vítimas, que efetuarão reconhecimento pessoal - Validade - Negativa isolada - Suficiência para a procedência da ação penal - Condenações mantidas - Causa de aumento do emprego de arma - Manutenção. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Causa de aumento do concurso de agentes. Manutenção. Palavra das vítimas, que foi explícita ao mencionar que os recorrentes agiram em conluio com, ainda, outros indivíduos. Pena. Elevação da pena base pelas circunstâncias do delito. Regime prisional fechado mantido. Delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Roubo circunstanciado. Apelo ministerial. Dosimetria. Agravamento da reprimenda. Circunstância judicial. Pena-base fixada acima do mínimo. Insuficiência. Gravidade da conduta que justifica a elevação pela metade. Concurso de agentes e emprego de arma. Acréscimo de 3/8. Causas de aumento bem dosadas. Apelo ministerial parcialmente provido.”(TJSP - APL nº 0.001.195-52.2004.8.26.0334 - Ac. 5.257.920 - Monte Aprazível - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Almeida Toledo - J. 12.07.2011 - DJESP 30.08.2011)-grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido.(STJ, AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Em suma: ficou evidenciado no decorrer da instrução que o acusado praticou o delito de roubo descrito na denúncia, sendo de rigor a condenação dele por infração ao

art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é duplamente reincidente (fls. 34/35 e 69).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, utilizando parte de suas reincidências e sua personalidade claramente voltada para o roubo, que aparentemente é seu meio de vida, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, com valor unitário mínimo.

Compenso a confissão com a reincidência.

Pela causa de aumento do roubo - concurso de agentes -, de rigor a exasperação da pena em 1/3, totalizando seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa.

Deixo de adotar o postulado pelo douto Dr. Defensor Público, de aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, por entender que se trata de uma discricionariedade do julgador - "art. 68 (...) Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua" (grifei) - e não se pode equivaler as situações de ser roubado por mais de uma pessoa com a de ser roubado com superioridade numérica e também uso de arma de fogo. Tanto é uma situação mais grave esta última que o legislador, com o advento da Lei nº 13.654/18, ao inserir o §2º-A ao art. 157 do Código Penal, quis garantir o aumento em 2/3 da pena daquele que emprega arma de fogo em um roubo, bem como do que emprega explosivo ou análogo, pela periculosidade de tais condutas, independentemente das outras causas de aumento do §2º do mesmo dispositivo legal. Desta forma, respeitando a vontade do legislador, bem como a individualização das penas, entendendo que não se pode equalizar situações desiguais, ainda mais em delitos violentos, entendo que devem ser aplicadas as duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, tal como constantes da denúncia. De mais a mais, acabar-se-ia por atenuar fortemente o louvável intuito do legislador que, ao editar a Lei 13.654/18, atendendo a reclamos da maior parte da população brasileira, logicamente lograva punir com maior severidade o roubador aparelhado com armas de fogo que, todos os dias, tantas mortes de cidadãos de bem causam no curso de assaltos do estilo. No sentido da possibilidade da cumulação: STJ - HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018.

No caso em tela, obviamente houve uma conduta muito mais lesiva do réu, que estava com outro agente e ambos armados. Não se pode equipar a situação sofrida pela vítima com aquele que é roubado por uma só pessoa, ou por duas sem arma de fogo. Enfim, justificado o emprego das duas majorantes.

Neste sentido é o entendimento da Colenda 8ª Câmara do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas, com afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida. Bem delineada a incidência da aludida causa de aumento, prescindível, para tanto, a apreensão ou perícia do artefato, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores - Acusação requer a elevação da reprimenda, aplicando-se cumulativamente o aumento decorrente do reconhecimento do concurso de agentes e aquele relativo ao emprego de arma de fogo - Cabimento Suficientemente demonstrada a incidência de ambas as majorantes, as quais se mostraram igualmente determinantes na concretização do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, é o caso de adequar-se as penas impostas, nos moldes pretendidos pela Acusação Apelo defensivo não provido e apelo ministerial provido. (...) Na terceira etapa, razão assiste ao i. representante do órgão ministerial quando refere que o cálculo da pena fixada comporta reparo. Explico. Ocorre que diante do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal, entendeu o d. magistrado "a quo" pela aplicação apenas daquela prevista no §2º - A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, no importe de 2/3 (dois terços), com base no artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex. Data vênua,

entendo que tal interpretação veio a beneficiar indevidamente o acusado, mormente porque não se pode simplesmente igualar a ação daquele que age unicamente valendo-se de arma de fogo, com a daquele que, por exemplo, o faz também em concurso de agentes, o que via de regra reduz ainda mais a possibilidade de resistência da vítima e implica em maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. É necessário, a meu ver, analisar casos desta natureza com especial acuidade, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Não se pode olvidar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei n.º 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no §2º do art. 157 do Código Penal, sendo aplicadas frações variáveis e proporcionais à quantidade daquelas, de acordo com seu reflexo no caso concreto, evidentemente. E o que pretendeu a nova lei, como é cediço, foi conferir às ações criminosas praticadas mediante utilização de arma de fogo, tratamento mais enérgico, compatível com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância, sendo, pois, um contrassenso, que se ignorasse, agora, a existência concomitante de causas de aumento outras, que permanecem legalmente previstas e dispostas no parágrafo anterior. Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Câmara: “APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Recurso Defensivo buscando o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma (§2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal). Alegação de inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e impossibilidade de cumulação entre as referidas causas de aumento. Pedidos subsidiários de fixação de regime semiaberto e detração da pena. Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu que confessou parcialmente a prática delitiva, negando, apenas, o emprego de arma de fogo Vítima que confirmou que o réu praticou o delito de roubo em questão, com a participação de um comparsa e o emprego de armas de fogo, tendo sido ameaçada durante a empreitada criminosa. Réu e comparsa que subtraíram o veículo da vítima e se evadiram, tendo sido encontrados pela Polícia algumas horas depois, na posse do veículo subtraído Acusado que conduzia o carro roubado, e o colidiu durante a perseguição policial Reconhecimento pessoal positivo Palavra da vítima que merece credibilidade Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima Crime cometido com violência e grave ameaça. Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma sobejamente demonstradas pela prova colhida desnecessidade de apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando devidamente calcada em outros elementos de prova. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes Na terceira fase, causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, inciso I, que são perfeitamente cumuláveis, à luz do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal a eventual não cumulação de causas de aumento ou de diminuição é faculdade do Julgador, conforme expressamente previsto em lei alegada inconstitucionalidade material da fração de aumento trazida pela Lei nº 13.654/18 que não merece prosperar Legislador que previu fração de exasperação mais gravosa para conduta de lesividade mais elevada (emprego de arma de fogo), não havendo qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade manutenção das exasperações de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cumulativamente. (...) Recurso da Defesa desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019 grifos nossos). Com efeito, ao prever que 'no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição (...)', o parágrafo único do art. 68 do Código Penal estende ao julgador uma faculdade (e não um dever). Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores, bem destacado pela d. Procuradoria Geral em seu parecer: “(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa

de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (...)" (STJ, HC nº 472771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/12/2018). Também nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 -Voto nº 39.442 19 CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). (...). IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrao da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC 110.960/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014). E, no caso em apreço, é de ser dito que ambas as majorantes devem ser aplicadas. Sucede que, por um lado, conforme apontou a d. Procuradoria Geral, em consonância com o mencionado entendimento das Cortes Superiores, "não foi apresentada justificativa concreta para a opção pelo aumento único. A bem ver, houve mera invocação abstrata do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sem que se cogitasse da proporcionalidade da punição em relação aos fatos" (fls. 213). Por outro lado, observa-se que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor do acusado foram de fato determinantes para a rendição do ofendido e consumação da ação criminosa. No caso, não bastasse o delito ter sido perpetrado mediante uso de arma de fogo, os roubadores ainda se valeram da superioridade numérica (pelo menos dois agentes) para ameaçar a vítima, que teve o dinheiro do caixa do estabelecimento subtraído e, também, o veículo de sua propriedade, que se encontrava estacionado em frente ao local. Evidente que um único agente, ainda que munido de arma de fogo, teria encontrado maior dificuldade ou quicá resistência por parte do ofendido para efetuar tal ação, já que haveria de manter sozinho a vítima subjugada enquanto buscasse, após subtrair-lhe o dinheiro do caixa, adentrar ao veículo que estava estacionado junto à via pública e sair rapidamente na condução dele. Tais fatores, portanto, se mostram hábeis a justificar, com base no caso específico dos autos (exatamente conforme orienta a jurisprudência das Cortes Superiores), a necessidade de aplicação cumulativa das duas causas de aumento reconhecidas pela r. sentença condenatória, como requer o "Parquet". (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1501213-85.2018.8.26.0567 - Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS - j. 5/12/2019 - grifei).

Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando onze anos, um mês e dez dias de reclusão e pagamento de 43 dias-multa. Torno definitiva tal pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a



unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu JONAS FERREIRA LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de onze anos, um mês e dez dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 43 dias multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício.

Em atenção ao disposto no §2º, "c", e 3º ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela pena aplicada e pela DUPLA REINCIDÊNCIA EM ROUBO e esta nova condenação, indicando que o crime contra o patrimônio é seu meio de vida e que nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido: "tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro) e ainda "Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei). "Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA